

1500924-82.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, e afastando-se, por outro lado, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal (redutor - tráfico privilegiado), pelas razões abaixo mencionadas.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, pelo auto de exibição e apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500924-82.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500924-82.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237939/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 27111632 -

DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2237939 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRCIO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

MÁRCIO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e está sendo processado porque, no dia 30 de agosto de 2022, no horário e local mencionados na denúncia, teria guardado drogas, consistentes em 1.747 porções de cocaína (pesando 1.491 g), 03 tijolos de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha (pesando 2.015g), 475 porções de maconha (pesando 1.196g), e 339 porções de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado às fls. 95 e apresentou defesa preliminar às fls. 121/122.

A denúncia foi recebida às fls. 123/125.

Citado, em audiência de instrução e julgamento (fl. 150) foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação em comum com a Defesa sendo, ao final, realizado o interrogatório do acusado, conforme gravação audiovisual constante dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais, requereu a integral procedência do pedido acusatório, com a consequente condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, com a fixação, ainda, do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, em memoriais escritos de fls. 151/163, postulou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requereu, ainda, o reconhecimento das atenuantes genéricas da confissão espontânea e da menoridade relativa, a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, mediante detração, e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Por fim, pleiteou a concessão de liberdade provisória ao acusado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a integral procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, e afastando-se, por outro lado, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal (reduzido - tráfico privilegiado), pelas razões abaixo mencionadas.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecentes de fls. 09/10, pelas fotografias de fls. 28/31, pelos laudos periciais de exames químico toxicológico de fls. 102/104, 111/113, 114/116 e 117/119, pelo laudo pericial do local dos fatos de fls. 105 /110, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, restou certa e segura.

O réu Márcio Rodrigo Pereira dos Santos, por ocasião do interrogatório realizado na fase policial (fls. 05), permaneceu em silêncio.

Em juízo, confessou parcialmente o cometimento do delito, aduzindo que: possui 19 anos de idade; possuía 18 anos na data dos fatos; é amasiado; sua companheira está grávida de um filho seu; possui duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais equiparados ao delito de tráfico de drogas; ficou internado pelos períodos de 09 meses e 07 meses, aproximadamente; saiu da internação no dia 30 de janeiro de 2022; na data dos fatos, por volta das 21h, estava em casa; foi até a casa da sua sogra que fica na R. Dr. Albert Sabin, nº 95, no bairro Jardim Suely; estava com os familiares de sua companheira; alguns familiares dela foram embora; chamou sua esposa para que fossem para casa; acionou dois mototáxis para retornarem; foram em sentido à Av. Jerônimo de Camargo, onde fica Condomínio Residencial Jerônimo de Camargo; avistaram a viatura dos policiais militares; eles estavam vindo ao seu encontro; não demonstrou nenhuma atitude suspeita porque não trazia nada de ilícito consigo; de fato, guardava as drogas em sua casa mas não praticava a venda de entorpecentes; na busca pessoal, encontraram consigo apenas seu cigarro e seus pertences; a abordagem foi longe do Condomínio Residencial

Jerônimo de Camargo, ainda na metade do caminho entre a casa da sua sogra e a sua residência; no momento da abordagem, eles lhe pediram a senha do seu celular; disse a eles que eles não possuíam autorização para mexerem em seu celular pessoal; eles passaram a lhe fazer perguntas estranhas; eles perguntaram se já havia tomado choques em sua vida e se sabia nadar; disse a eles que não; disse a eles que não daria a senha do seu celular; eles disseram que iam lhe dar choques e que “ia ver”; tendo em vista que possui problemas de saúde e passou por cirurgia, sentiu medo de que o prejudicassem de alguma forma; passou a eles a senha do seu celular; eles visualizaram fotos suas com amigos seus que são envolvidos com o tráfico de drogas; eles visualizaram uma foto sua com seu primo que foi preso; eles perguntaram se conhecia “esse trouxa”; disse a eles que se tratava de seu primo; havia 03 viaturas da força tática, com aproximadamente 12 policiais; eles disseram que haviam prendido seu primo e disseram que iriam lhe prender também; eles disseram que havia denúncias envolvendo sua casa e perguntaram seu endereço; disse a eles que não forneceria seu endereço porque eles não possuíam autorização para ir até sua residência; eles o ameaçaram novamente de lhe desferir um choque; disse a eles que não fizessem isso “pelo amor de Deus”; eles ordenaram que lhes passasse seu endereço; se sentiu muito pressionado de que eles pudessem lhe fazer mal; forneceu seu endereço por esse motivo; de fato, guardava os entorpecentes em sua residência; sabe que isso não era certo; não encostava nas drogas; apenas recebia dinheiro para que eles armazenassem as drogas em sua residência; quando lhe visitou, sua esposa contou que pediu ao mototaxista que parasse para acompanhar a abordagem, sendo que ele negou porque a motocicleta estava com os documentos vencidos; quando foi abordado, estava em cima da motocicleta; eles ordenaram que encostasse a motocicleta e ordenaram que colocassem as mãos em cima da cabeça; eles o retiraram da motocicleta e o separaram do mototaxista; conhece o mototaxista pela alcunha “Tuti”; não trazia nenhuma droga consigo quando foi abordado; não vendia drogas; estava em poder das chaves quando foi abordado; residia sozinho no local dos fatos; sua companheira residia com a mãe dela; não conhecia os policiais que prestaram depoimento em juízo, anteriormente; conhecia os quatro policiais que o abordaram, inicialmente, porque foram os mesmos que abordaram seu primo; não foi encontrado dinheiro consigo; guardava embalagens e balanças em sua residência para os seus amigos; guardava os entorpecentes há cerca de 09 dias; sabe que nada justifica ter cometido o crime; estava passando por um momento de desespero; sua mãe estava com muitas dificuldades financeiras e sua esposa estava grávida; estava passando por dificuldades financeiras.

Tal versão dos fatos, no entanto, merece ser considerada apenas em parte pelo Juízo.

Isto porque o policial militar Douglas Rodrigues Gonçalves, em juízo, relatou que: na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local; o local é conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas; ao perceber a presença da viatura, o acusado mudou o sentido da caminhada; realizada busca pessoal, encontraram com ele cerca de 30 porções de crack no bolso da blusa dele; tratava-se de uma “blusa de frio”; ao indagar onde ele residia, ele passou o endereço; possuíam denúncias anteriores de tráfico no local; ao indagar o acusado, ele acabou por confessar que recebia a quantia de R\$ 200,00 para armazenar entorpecentes no local; no local apontado pelo acusado encontraram drogas conforme ele havia mencionado; trata-se de um cômodo que estava trancado; acusado abriu o cômodo com a própria chave, que estava pendurada em uma corrente em seu pescoço; no local, encontraram grandes quantidades de cocaína, maconha e crack, além de uma balança e embalagens vazias; as embalagens encontradas ficaram guardadas em uma gaveta no local; a balança foi apreendida; o dia seguinte aos fatos, conduziram o acusado até a delegacia; na delegacia, conversando com o acusado, lembraram de que conheciam o acusado de uma abordagem realizada com um parente dele; não se recordavam do acusado até então; não havia outras pessoas no interior do apartamento;

Por fim, o policial militar Lucas Lozardo Cavalcante, em juízo, narrou que: na data

dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local; o local é conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas; ao perceber a presença da viatura, o acusado mudou o sentido da caminhada, o que chamou a atenção da equipe; realizada busca pessoal, encontraram com ele cerca de 30 porções de crack no bolso da blusa dele; ele possuía uma corrente do pescoço com uma chave; indagado sobre a chave, ele disse que se tratava de um apartamento do qual ele tomava conta; ele disse que havia mais drogas naquele local; tendo em vista a confissão do acusado, aliada a outras denúncias anônimas que já possuíam acerca daquele apartamento em específico, decidiram realizar diligências no apartamento; no local, localizaram grandes quantidades de drogas diversas como crack, maconha e cocaína, além de uma balança e uma faca; diante dos fatos, conduziram o acusado até a delegacia; não havia abordado o acusado em outras ocasiões anteriores aos fatos; não havia outras pessoas no interior do imóvel; o acusado disse que recebia R\$ 200,00 para "tomar conta" das drogas no referido apartamento.

Nesse contexto, dúvidas não restam acerca da caracterização do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, pelos seguintes motivos: I - relativa quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado (30 porções de crack); II - grande quantidade e variedade de drogas apreendidas na residência do acusado, totalizando 1.747 porções de cocaína, 03 tijolos de maconha, 475 porções de maconha e 339 porções de crack, além de quatro balanças de precisão e quatro aparelhos celulares; III - local conhecido nos meios policiais como ponto de intenso tráfico de entorpecentes; IV - depoimentos harmônicos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo; V - confissão informal do acusado aos policiais militares no momento da abordagem; VI - confissão parcial do acusado, em Juízo; e VII - o acusado já foi internado na Fundação Casa, quando menor de idade, devido à prática de dois atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, tanto em solo policial quanto em juízo, apresentaram versão harmônica dos fatos, no sentido de que, na data dos fatos, visualizaram o acusado em atitude suspeita, tendo mudado a direção da caminhada ao perceber a presença da viatura, motivo pelo qual procederam a abordagem.

Narraram, ainda, que, ao abordarem o acusado, e, tendo realizado busca pessoal, encontraram com ele a quantia de 30 porções de crack, no bolso da blusa dele, além de uma chave pendurada por um cordão, em seu pescoço.

Aduziram que, ao ser questionado, o acusado informou que a localização do imóvel da qual a chave pertencia e confessou informalmente que armazenava drogas no local, recebendo a quantia de R\$ 200,00 semanais para tanto.

Afirmaram, ainda, que, na sequência, se dirigiram ao local e lá encontraram grande quantidade de entorpecentes, totalizando 1.747 porções de cocaína, 03 tijolos de maconha, 475 porções de maconha e 339 porções de crack.

O acusado, por sua vez, em juízo, confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que estava guardando as drogas, para fins de tráfico de drogas, recebendo a quantia de R\$ 200,00 para tanto.

Tal confissão, ainda que parcial, a toda evidência, merece ser considerada pelo Juízo como meio de prova, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, haja vista se encontrar em consonância com as demais provas carreadas aos autos, mormente com o depoimento dos policiais militares.

Destaco que, em que pese o réu alegar, em juízo, que não trazia as 30 porções de crack consigo no momento da abordagem, tal versão restou isolada, em total dissonância com a prova testemunhal.

Isto porque, tanto na fase policial quanto em juízo, os policiais foram firmes no sentido de que, realizada busca pessoal, encontraram com o acusado a quantia de 30 porções de crack, embaladas em embalagens individuais, prontas para venda.

A par disso, insta ressaltar que não há que se falar em ausência de credibilidade no relato de servidores policiais, à medida que, na condição de testemunhas, suas palavras ostentam o mesmo valor probatório que o de qualquer outra, não se podendo retirar a boa-fé pelo só fato de serem agentes de segurança. Nesse sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na verdade, o testemunho de servidores policiais merece fé até prova em contrário (RT 426/439), desde que não fique demonstrada a sua inidoneidade (RT 444/406), ou o seu propósito deliberado de incriminar falsamente o réu (RT 454/422), o que não se verificou na hipótese dos autos, até mesmo porque eles sequer conheciam o réu anteriormente aos fatos.

Acerca da busca domiciliar realizada, saliento que a entrada em domicílio se deu logo após a flagrância do réu com substâncias entorpecentes em outro local, o que denota que a busca foi amparada em fundadas razões.

Aliás, sobre o tema, leciona, com acerto, Renato Brasileiro de Lima (in “Legislação Criminal Especial Comentada: volume único”, 5ª edição, Editora JusPODIVM, 2017, pág. 1008) que: “...em seu art. 5º, XI, a própria Constituição Federal autoriza a violação ao domicílio nos casos de flagrante delito, seja durante o dia, seja durante a noite, e independentemente de prévia autorização judicial. Em relação aos crimes permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Logo, estando o agente em situação de flagrância no interior de sua casa, será possível a violação de domicílio mesmo sem mandado judicial.”

Nesse mesmo sentido, saliento que - não ignorando o respeitável entendimento das 5ª e 6ª Turmas do C. Superior Tribunal de Justiça (3ª Seção, em sua integralidade, portanto) no sentido de que cabe ao Estado demonstrar, de modo inequívoco, o consentimento expresso do morador para a entrada da polícia em sua casa, quando não houver mandado judicial - o C. Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, vale realçar, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - se estiver amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Não obstante, no caso em tela, relataram os agentes policiais a existência de denúncia anterior apontando a ocorrência de traficância no exato local apontado pelo acusado como sendo a sua residência.

Diante deste cenário, dúvidas não restam quanto à existência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a busca domiciliar realizada após a abordagem do acusado.

Quanto à não utilização de câmeras pelos policiais no momento da abordagem ou, ainda, durante a busca na residência, entendo que não houve irregularidade, haja

vista decisão da 6ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, datada de março deste ano, que concedeu, para tanto, o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).

Ademais, de se consignar que eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial (tanto na prisão em flagrante quanto no inquérito policial) caracterizam mera irregularidade, e não nulidade, de forma que não contaminam a ação penal subsequente, conforme orientação majoritária da doutrina e da jurisprudência, sobretudo do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo.

Há que se observar, ainda, que o réu se encontrava em poder de drogas e de chaves, estas devidamente apreendidas nos autos, informando aos policiais, de forma colaborativa, acerca do local em que havia mais entorpecentes, fornecendo detalhes do rendimento semanal (R\$ 200,00).

Outrossim, ainda que não aduzido de forma expressa pela Defesa, sublinho que a alegação do réu, de que estava passando por dificuldades financeiras à época dos fatos (tese de autodefesa), não se revela suficiente, no caso em tela, para eventual reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Acerca do assunto, ensina Cleber Masson ("Código Penal Comentado", Editora Método, 3ª edição, 2015, p. 195/196), ao comentar a distinção entre a referida excludente (estado de necessidade) e as dificuldades econômicas, que: "Não se confundem. No estado de necessidade, o agente é compelido a praticar o fato típico, para afastar a situação de perigo atual ou iminente, involuntário e inevitável, capaz de afetar bem jurídico próprio ou de terceiro, cujo sacrifício é inexigível. Na dificuldade econômica supõe-se que o indivíduo deva conformar-se com a privação, porque não se cuida do suprimento de necessidade vital ou primária, ou, ainda que disso se trate, que lhe seja possível satisfazer a carência por meio de atividade lícita. Em qualquer das hipóteses não se justifica a lesão ao interesse de outrem. Destarte, a dificuldade econômica, inclusive com a miserabilidade do agente, não constitui estado de necessidade. Em casos excepcionais, admite-se a prática de um fato típico como medida inevitável, ou seja, para satisfação de necessidade estritamente vital que a pessoa, nada obstante seu empenho, não conseguiu superar de forma lícita, a exemplo do furto famélico, em que o sujeito subtrai alimentos básicos para saciar a sua fome ou de pessoa a ele ligada por laços de parentesco ou de amizade. Portanto, se o agente podia laborar honestamente, ou então quando se apodera de bens supérfluos ou em quantidade exagerada, afasta-se a justificativa".

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça também decidiu que:

"Estado de necessidade - dificuldades financeiras - não caracterização: a afetação da qualidade de vida, mesmo implicando em dificuldades financeiras, por si só, não preenche os requisitos do status necessitatis (art. 24 do CP)" (REsp 499.442/PE, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 24.06.2003)

Ademais, imperioso destacar que o acusado não comprovou a existência de dificuldade econômica e de perigo atual que justificassem o sacrifício de bem alheio, ônus da prova que, a toda evidência, lhe competia (art. 156, do Código de Processo Penal).

Em outras palavras, a conduta do acusado não se amoldou às condições necessárias ao reconhecimento do estado de necessidade, razão pela qual se revela impossível o seu reconhecimento no caso concreto.

Portanto, considerando o panorama fático e probatório acima descrito, dúvidas não restam quanto à caracterização do delito descrito na inicial acusatória.

Reconhecida a autoria do crime de tráfico de drogas, entendo, todavia, que o acusado não faz jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista as suas duas condenações anteriores, com trânsito em julgado, pela Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais equiparados ao delito de tráfico de drogas (cf. certidões de fls. 78/93 – Autos 1501239-83.2021.8.26.0048 e 1500838-21.2020.8.26.0048, ambos da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude desta Comarca de Atibaia, tendo este último fato ocorrido em 04/06/2020, medida socioeducativa de internação revogada em 05/03/2021), circunstância esta que, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, indica efetiva dedicação a atividades criminosas.

Nesse ponto, destaco que este Juízo levará em consideração a referida condenação pela prática de ato infracional a fim de afastar o redutor, tendo em vista guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Nesse sentido, o entendimento firmado pela Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.916.596/SP, tendo sido reconhecida a possibilidade, em tese, de considerar atos infracionais como fundamento idôneo a demonstrar dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, quando contemporâneos ao delito em julgamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL E DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 5. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). 6. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EResp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção). 7. A presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se na simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva, no registro de atos infracionais e na quantidade de droga apreendida não se harmoniza com a orientação predominante do STF. 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 613508 SC 2020/0240550-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP.

Neste particular, a fim de evitar “bis in idem” na utilização de elementos

idênticos em fases distintas da dosimetria, este Juízo não considerará, para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, a diversidade e a quantidade de drogas, que serão consideradas, portanto, apenas na 1ª fase, abaixo.

Levei em consideração, ainda, a apreensão, no interior do imóvel, das balanças de precisão.

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, impõe-se a condenação do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas, afastando-se, ainda, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do referido diploma legal (tráfico privilegiado).

Verificadas, assim, materialidade e autoria delitivas, passo, pois, à fixação da pena.

Na dosagem da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei de Tóxicos, verifico que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo vista a diversidade (cocaína, maconha e crack) e a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos (1.747 porções de cocaína, 03 tijolos de maconha, 475 porções de maconha e 339 porções de crack). A prática dos atos infracionais (equiparados ao delito de tráfico de drogas) – circunstância desfavorável relacionada à personalidade – será levada em consideração apenas na 3ª fase, a fim de afastar o redutor do tráfico privilegiado. Assim, elevo a pena mínima em 1/3, perfazendo a pena-base 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que há incidência das atenuantes genéricas da menoridade relativa (o acusado possuía 18 anos de idade na data dos fatos), bem como da confissão, ainda que parcial, de forma que reduzo a pena em 1/5, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão, e 532 dias-multa. No mais, destaco que o acusado é tecnicamente primário, cf. pesquisa SIVEC de fls. 21/33 e certidão de fls. 34).

Finalmente, na terceira fase, consigno que o acusado não faz jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pelos motivos supramencionados.

Ausentes demais circunstâncias modificadoras da pena, torno definitiva a pena acima fixada, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão, e 532 dias-multa.

O dia-multa será fixado em seu mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira do acusado, salvo aquela genericamente mencionada por ocasião de seu interrogatório judicial, insuficiente para tal finalidade.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima mencionadas (1ª fase de aplicação da pena), e a gravidade em concreto da conduta do acusado, nos termos do quanto disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal (quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes; passagens do réu na Vara da Infância por dois atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas), não desconhecendo este Juízo, todavia, a tese de Repercussão Geral fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1052700, de relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, no sentido da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos. Ademais, a fixação de regime inicial mais brando não alcançaria, de forma expressiva, os objetivos de repressão e prevenção visados pelo Direito Penal. Por fim, não tendo o Juízo reconhecido o tráfico privilegiado, inaplicáveis as recentes determinações do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de HC Coletivo (final do ano de 2020), observando-se, ainda, a apreensão de duas balanças de precisão no interior do imóvel.

Destaco, ademais, que não se mostra cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista a quantidade de pena aplicada à ré (superior a 04 anos) – art. 44, inc. I, do Código Penal. Ainda, de se observar que tal medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso – requisitos subjetivos (art. 44, inc. III, do Código Penal).

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez presentes os requisitos que culminaram com a decretação de sua prisão preventiva. A detração, para fins de eventual progressão (o réu se encontra preso preventivamente há cerca de 03 meses), deverá ser melhor analisada pelo Juízo das Execuções, inclusive em sede de execução provisória, não vislumbrando o Juízo da condenação motivo plausível e evidente para alteração do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo integralmente PROCEDENTE o pedido acusatório constante da ação penal proposta pelo Ministério Público contra MÁRCIO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS e assim o faço para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 532 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial fechado, sem conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, e com o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado:

I - lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos); e

III - oficie-se ao Setor de Armas e Objetos local para que promova a devida destinação com relação aos objetos apreendidos às fls. 07/08, ou, se o caso, à Central de Custódia do Instituto de Criminalística de Bragança Paulista.

O réu está isento do pagamento de custas processuais, uma vez que se encontra assistido por Defensora nomeada em razão do convênio firmado entre a OAB/SP e a DPE/SP (fls. 97), presumindo-se, assim, o seu estado de miserabilidade e a impossibilidade financeira de arcar com tal despesa. Após a confirmação da interposição ou não de recurso, expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor nomeado.

P.I.C.

Atibaia, 07 de novembro de 2022.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA